

1500464-73.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... na sua forma trazer consigo para fins de tráfico.

Vejamos.

O acusado, interrogado na fase policial disse que era olheiro do tráfico. Negou, contudo, que a droga apreendida lhe pertencia.

Em juízo confessou afirmou que estava na função de olheiro. Quem arremessou a sacola foi outra pessoa. Estava auxiliando outro traficante. Ganhava R\$ 200,00. Aquele era o primeiro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

4ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos - SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500464-73.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500464-73.2022.8.26.0617 - Controle nº 2022/000321

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY WENDELL MONTEIRO DA SILVA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA

WESLEY WENDELL MONTEIRO DA SILVA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 06 de abril de 2022, por volta das 9h45, na avenida dos Evangélicos, altura do nº 1.744, Campo dos Alemães, nesta, trazia consigo substância entorpecente para fins de tráfico.

Guardas Municipais avistaram o acusado em via pública com uma sacola. Ao visualizar a aproximação da viatura o acusado tentou fuga, arremessando a sacola ao chão. Foi perseguido e detido. Recuperada a sacola os guardas localizaram o entorpecente e dinheiro. Foi preso.

Houve oferta de defesa preliminar.

Recebida a denúncia foram ouvidas testemunhas e o acusado interrogado ao final.

Em alegações finais o Ministério Público protestou pela procedência.

A defesa disse que a prisão do acusado é nula em razão da atuação da guarda municipal; o réu confessou que atuava apenas como "olheiro"; que a pena deve ser a

mínima; alegou questões de regime e substituição; recurso em liberdade.

Relatei.

Decido.

A ação penal é procedente.

De início há falar que não vinga a suscitada ilicitude das provas decorrentes da atuação dos guardas municipais, pois legítima a diligência realizada pelos mencionados agentes públicos.

Primeiro, porquanto o Estatuto das Guardas Municipais (Lei 13.022/14) conferiu poder de polícia à referida classe, elencando, dentre as suas competências específicas, a de "colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações que contribuam com paz social".

Segundo, levando-se em conta que, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal, "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito".

No presente caso, durante patrulhamento os guardas flagraram o acusado praticando tráfico de drogas crime permanente, de maneira que, agindo em defesa da sociedade, podiam e deviam tomar medidas para fazer cessar as atividades ilícitas, haja vista a fundada suspeita da prática criminosa.

Ora, se a qualquer do povo é permitido prender quem quer que seja encontrado em situação flagrancial, a conduta dos guardas municipais, neste caso, insere-se, por certo, dentro de um parâmetro de razoabilidade, sob pena de inviabilizar o preceito legal ou transformá-lo em letra morta.

A propósito, confira-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVISTA FEITA POR GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCENTE. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, § 2º, A, DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. SÚMULA 269/STJ. INAPLICABILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Embora exista norma constitucional (art. 144, § 8º, da CF) limitando a função da guarda municipal à proteção dos bens, serviços e instalações do município, não há nulidade na decisão impugnada, porquanto a lei processual penal em seu art. 301 do CPP, disciplina que 'qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito'. (...). Ordem denegada". (HC 109105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.2010).

Na mesma trilha, já julgou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"PROVA ILÍCITA Imputação de nulidade da ação penal Inocorrência Guardas Municipais que, assim como qualquer pessoa do povo, têm aptidão para exercer a prisão no caso de flagrante delito Incidência do art. 301 do Cód. de Processo Penal Precedentes." (Apelação nº 0067759-11.2012.8.26.0050, 7ª Câ. Crim., Rel. Roberto Solimene, j. em 06/02/2014).

"Releva notar, de início, que não há qualquer irregularidade na prisão em flagrante do paciente, efetuada pela guarda municipal. Ora, se qualquer do povo pode conduzir alguém até uma delegacia, evidente que assim também podem agir os guardas municipais. Aliás, como já reconheceu o C. Superior Tribunal de Justiça, embora a guarda municipal, a teor do disposto no § 8º, do art. 144, da Constituição Federal, tenha como tarefa precípua a proteção do patrimônio municipal, tal limitação 'não exclui nem retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de auto defesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do art. 301 do Código de Processo Penal. Nestas circunstâncias, se a lei autoriza a prisão em flagrante, evidentemente que faculta também a apreensão de coisas, objeto do crime' (STJ, 6ª Turma, RHC 7916/SP, rel. Min. Fernando Gonçalves - DJU de 09/11/98, pág. 175 ou JSTJ, 115/302)." (Habeas Corpus nº 2074558-21.2014.8.26.0000, 9ª Câ. Crim., Rel. Sérgio Coelho, 26/06/2014).

Rejeita-se, assim, a prejudicial invocada.

Passo ao mérito.

Como é cediço, para que se faça possível a decisão condenatória dois requisitos se mostram absolutamente necessários, sem os quais se impõe a absolvição.

Primeiro deve estar provada a materialidade, que, in casu, qualquer dúvida resta,

ante a análise dos autos de constatação, exibição, apreensão e laudo toxicológico. Resta o segundo - autoria - ter a real certeza de que o sujeito ativo praticou o fato descrito na norma penal incriminadora.

Neste ponto, também nenhuma dúvida há posto que sobejamente comprovado nos autos que o acusado praticou o fato descrito na norma penal inserta no art. 33 da Lei 11.343/06, na sua forma trazer consigo para fins de tráfico.

Vejam os.

O acusado, interrogado na fase policial disse que era olheiro do tráfico. Negou, contudo, que a droga apreendida lhe pertencia.

Em juízo confessou afirmou que estava na função de olheiro. Quem arremessou a sacola foi outra pessoa. Estava auxiliando outro traficante. Ganhava R\$ 200,00. Aquele era o primeiro dia.

Corroborando a confissão do acusado afirmaram os guardas municipais que realizavam patrulhamento pelo local dos fatos quando avistaram o acusado vendendo entorpecente a usuário. Ao avistar a viatura, o acusado arremessou a sacola que carregava e tentou fugir. Foi perseguido e detido. Em revista pessoal, foi localizado um celular. Recuperada a sacola foram apreendidas 30 porções de cocaína, 40 porções de crack e 40 porções de maconha, além de R\$ 287,00. Indagado, o acusado confessou a autoria do delito, afirmando que trabalhava como "olheiro" do tráfico. Negou, contudo que a droga apreendida lhe pertencia. Os guardas ainda contaram que com o comprador foi localizada uma porção de maconha e dinheiro. Disseram, por fim, que o usuário afirmou que havia comprado a porção de maconha com o acusado.

Já a testemunha Wesley afirmou que o acusado estava na função de "campana" e que havia adquirido a droga de terceira pessoa.

Da análise de todo o processado percebe-se que não existe espaço a dúvidas.

Não porque o acusado confessou a autoria. Embora tivesse negado estivesse na posse da droga apreendida, confirmou que estava a serviço do vil comércio.

Os guardas municipais, por seu turno, mantiveram a versão declinada à autoridade policial, inclusive no que pertine ao fato de que foi o acusado quem lançou a sacola com entorpecente, sendo certo que nada há nos autos dando conta estivessem mentindo.

Além disso, no reverso daquilo que pensa parte da jurisprudência, entendo que a apreensão de quantidade excessiva do entorpecente é meio de prova quanto ao comércio do mesmo, e não mera presunção.

É claro que, por si só, a quantidade não é suficiente para reconhecer o tráfico, mas, cotejada com outros elementos de prova e circunstâncias da apreensão, mostra-se meio hábil e legítimo para sustentar a ocorrência da mercancia.

A jurisprudência tem se alinhado à tese:

"Levando-se em conta a grande quantidade de entorpecente encontrada, seu valor e o escasso poder de compra do acusado, aliando-se ao fato de que levava para o local de serviço, tem-se que está correta a classificação no artigo 12 da Lei nº 6.368/76" (TJSP, rel. Gentil Leite, RT 710/279).

"Tráfico - Apreensão de grande quantidade de maconha - Objetivo de comercialização indiscutível, ainda que se trate de réu dependente da erva entorpecente - Condição de traficante que se prepondera sobre a de viciado, posto que tinha ele o entendimento da ilicitude do tráfico" (TJSP - rel. MARINO FALCÃO, RJTJSP 84/382).

Some-se, pois, à quantidade do entorpecente apreendido o modo pelo qual estava embalada a droga encontrada em poder do acusado.

É cediço que, em casos de tráfico, a substância entorpecente, no mais das vezes, está embalada de forma individual para facilitar o comércio a terceiros. O mesmo caminho trilha a jurisprudência:

"Caracteriza o delito de tráfico ilícito de substância entorpecente trazer consigo, sem autorização legal ou regulamentar, maconha e cloridato de cocaína, em doses unitárias, de pequenos embrulhos, embalagem usual do varejo das drogas" (TJRJ - rel. ENÉAS MACHADO COTTA, RDTJRJ 23/288).

"Identificando o fornecedor das substâncias tóxicas, em poder de quem foi apreendida expressiva quantidade de cocaína, parte já dividida em dezenas de papérolas, prontos para entrega a consumo, impõe-se a condenação por tráfico, sem que se possa, todavia, reconhecer associação com compradores" (TJRJ - rel. PAULO

GOMES DA SILVA FILHO, RDTJRJ 20/313).

Dispõe o art. 29 do Código Penal: "Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade".

Por isso não se cogita a hipótese de subsunção dos fatos ao tipo penal do artigo 37.

Não porque aqui o acusado agia para a prática do tráfico, inclusive in loco. Não se trata de mero colaborador, mas de executor.

Neste sentido vem decidindo a Jurisprudência:

"2. A norma incriminadora do art. 37 da Lei nº 11.343/2006 tem como destinatário o agente que colabora como informante com grupo (concurso eventual de pessoas), organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.694/2012) ou associação (art. 35 da Lei nº 11/343/2006), desde que não tenha ele qualquer envolvimento ou relação com as atividades daquele grupo, organização criminosa ou associação para as quais atua como informante. Se a prova indica que o agente mantém vínculo ou envolvimento com esses grupos, conhecendo e participando de sua rotina, bem como cumprindo sua tarefa na empreitada comum, a conduta não se subsumi ao tipo do art. 37 da Lei de Tóxicos, mas sim pode configurar outras figuras penais, como o tráfico ou a associação, nas modalidades autoria e participação, ainda que a função interna do agente seja a de sentinela, fogueteiro ou informante. 3. O tipo penal trazido no art. 37 da Lei de Drogas se reveste de verdadeiro caráter de subsidiariedade, só ficando preenchida a tipicidade quando não se comprovar a prática de crime mais grave. De fato, cuidando-se de agente que participa do próprio delito de tráfico ou de associação, a conduta de colaborar com informações para o tráfico já é inerente aos mencionados tipos. Considerar que o informante possa ser punido duplamente, pela associação e pela colaboração com a própria associação da qual faz parte, além de contrariar o princípio da subsidiariedade, revela indevido bis in idem" (STJ, HC 224849/RJ Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze Quinta Turma DJe 19/06/2013).

É imperioso o reconhecimento da figura do tráfico de entorpecente prescrita pelo artigo 33 da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Ao que consta o réu é tecnicamente primário.

No mais, as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhes são favoráveis, assim como o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/06.

Estabeleço a pena base no mínimo em 05 (cinco) anos de reclusão, além da pecuniária de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados na proporção mínima cominada em lei.

Milita em favor do acusado a circunstância atenuante da confissão espontânea.

Contudo, pena-base fixada no mínimo, inviável sua redução.

Preso na posse de significativa quantidade de entorpecente, sem comprovar ocupação lícita, havendo confessando aos guardas que estava traficando, nota-se, de forma clara que vinha fazendo do crime meio de vida, dedicando-se exclusivamente às atividades criminosas.

Aliás, a fls. 93/131 estão certidões dando conta de que o acusado está envolvido com o vil comércio desde há muito, demonstrando de forma inequívoca que se dedica sim às atividades criminosas.

Por isso, não faz jus à atenuante prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Não porque assim dispõe o citado dispositivo:

"Parágrafo quarto - Nos delitos definidos no caput e no parágrafo primeiro deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa." (negritei)

Releva notar que o dispositivo supracitado exige apenas que o acusado se dedique a atividades criminosas, nada mais do que isso.

Ou seja, basta que faça daquela atividade algo corriqueiro, cotidiano, como acabou demonstrado nestes autos.

Não há necessidade de associação à "facção" criminosa ou ao crime organizado. Basta que se dedique.

Quem se submete a cumprir jornada de trabalho numa biqueira, obviamente, se dedica

às atividades criminosas.

Neste sentido restou decidido em recurso de apelação nº 0035632-25.2011.8.26.0577, oriundo desta Vara, cujo Relator foi Desembargador Geraldo Wohlers.

"Ressalte-se que a diminuição hoje admitida pelo artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, não se mostrava viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade dos agentes.

O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno. A mens legis da Lei nº 11.343/06 há de ter tido em vista, primordialmente, fornecedores ocasionais, que não denotam perseverança criminosa, hábito delinquencial ou gravíssimo comprometimento para a ordem social, a paz coletiva e a saúde da população em geral, virtudes certamente irreconhecíveis no imperdoável traficante de drogas que persevera nessa senda.

Tanto, aliás, que o citado art. 33, § 4º, contém expressa referência, para fins de merecimento da redução condescendente, à exigência de que o agente "não se dedique às atividades criminosas".

Sabe-se que em termos repressivos o intuito constitucional é o de desestimular com energia o comércio ilegal de drogas; logo, o benefício trazido pela nova lei de regência, editada sob o mote de tornar mais rigoroso o tratamento penal que incide sobre o traficante, conflita, quando aplicado de modo indiscriminado, com a Constituição da República. Há, além da quebra do princípio de isonomia entre os condenados por outros crimes (especialmente pelos classificados como igualmente hediondos) e os condenados por tráfico de drogas, uma violação às disposições constitucionais e aos tratados internacionais que obrigam o Poder Público brasileiro à repressão efetiva do narcotráfico.

A intelecção útil e legítima da norma sob análise só pode ser feita à luz da Carta Política, e nesse passo se conclui que a mercê foi estabelecida para dar solução excepcional a situações excepcionais.

A lei atual trouxe tratamento distinto para quem oferece droga a pessoa de seu relacionamento sem objetivo de lucro a rigor, traficante de entorpecentes: § 3º do mesmo artigo 33.

Ora, também se reserva tratamento diferenciado no § 4º, pois o redutor se dirige a quem comete uma das condutas puníveis constantes do caput ou do § 1º do artigo 33 quando o agente atua sem ter o lucro por meta, sem intuito de comércio, sem adotar a odiosa e desagregadora propagação narcótica como meio de vida.

É assim que se deve considerar a exigência de "não se dedicar às atividades criminosas" (terceira figura dos pressupostos indispensáveis à concessão da benesse), porque quem procura obter vantagem financeira através do mercadejo de substância clandestina se propõe, claro, a exercer atividade criminosa: presta o torpe serviço para alguém, faz a deplorável intermediação para alguém, busca aumentar os recursos ilícitos de grupos ou organizações formadas à margem da lei para custear investidas delituosas n'outros setores do submundo. Convenhamos ser fenômeno de extrema raridade o traficante que age solitariamente.

Se se der outra interpretação ao dispositivo em apreço, de forma a alcançar todo e qualquer agente que preencha os demais requisitos, haverá incontornável discrepância com outras normas da mesma Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, como, por exemplo, a descrição típica de seu artigo 37 (mero informante).

No caso concreto apurou-se que o acusado estava desempregado e, não obstante, detinha considerável quantidade de cocaína e de crack para expor à venda em local conhecido como pólo de mercancia, inferindo-se do entrelaçamento desses dados que, quando de sua prisão, o réu estava a exercer a mercancia ilícita como meio de vida - o que desautorizava, sem dúvida, a causa de diminuição colimada."

Nos termos do que dispõe a Lei 8.072/90, com redação alterada pela Lei nº 11.464, de 28.03.2007 (DOU 29.03.2007), bem como que o sentenciado se encontrava "batendo ponto" numa biqueira, trabalhando para o vil comércio e na posse de boa quantidade de entorpecente, o regime inicial somente pode ser o fechado.

E por que é assim?

É assim porque o tráfico de entorpecentes fomenta outros crimes. Infiltra-se na sociedade e é praticado, inclusive, dentro dos presídios.

Não se trata mais de crime que no passado era praticado de forma individual.

Atualmente, tanto o pequeno traficante, quanto o grande, fazem parte de um grande organismo, uma verdadeira indústria, e a retirada dos traficantes das ruas é um dos meios de combate ao crescimento desta indústria.

Por isso, buscando principalmente a manutenção da ordem pública, o único regime possível é o fechado.

Preso em flagrante, convertida em preventiva, processado e condenado, ainda persistem os requisitos para manutenção da custódia cautelar, daí porque nego o apelo livre.

Anoto que é impossível a substituição ou o sursis diante da pena fixada.

Diante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para:

CONDENAR, WESLEY WENDELL MONTEIRO DA SILVA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão em regime inicial fechado, e no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, cada qual na proporção mínima cominada em lei.

Nego o apelo em liberdade.

Recomende-se.

Declaro o perdimento do dinheiro apreendido, eis que comprovado sua origem ilícita. Eventualmente desafiado o julgado, e sendo o(s) recurso(s) tempestivo(s), após a última intimação das partes, pessoal, na pessoa do advogado ou por edital, abra-se vista para, no prazo legal, apresentação de razões e contrarrazões de apelação, remetendo-se em seguida os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Seção de Direito Criminal, com as homenagens deste Juízo.

Mais a mais, quando da remessa, conforme artigo 380, § 3º, das NSCGJ, anote-se na capa, se físico, ou em pendência no sistema SAJ, se digital, o termo final da prescrição.

Não desafiado, e/ou advindo o trânsito em julgado, cumpra-se a decisão de praxe deste juízo e, se o caso, expeça(m)-se mandado(s) de prisão em desfavor da(o)(s) ré(u)(s), bem com a(s) respectiva(s) guia(s) de recolhimento para o devido cumprimento da pena imposta a(o)(s) sentenciada(o)(s), intime-se a(o)(s) ré(u)(s) para pagamento das custas e taxas processuais e, em relação à multa penal, com cobrança e, se necessário, execução, proceda-se nos termos do Provimento CG nº 5/22 (verificação de fiança recolhida nos autos, atualização, compensação/ abatimento ou extração de certidão de sentença ao MP); oficie-se à(s) vítima(s), ao setor de objetos apreendidos, cumprindo-se, ainda, o determinado na sentença com relação ao perdimento de bens/valores apreendidos, com comunicação à SENAD nos termos do Comunicado CG nº 280/19, DJe de 06.03.2019.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Arquivem-se os autos oportunamente, com as comunicações e anotações de praxe.

P.I.C.

São José dos Campos, 20 de junho de 2022.

CARLOS GUTEMBERG DE SANTIS CUNHA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA